

1502592-18.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pinati da Silva

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... o caso, responder pela "participação no crime de tráfico (arts. 33, caput e § 1º, e 34)."451 Esse entendimento peca por consentir com a punição muito mais severa do agente que colabora eventualmente com informações prestadas a um traficante solitário (partícipe do tráfico), em relação àquele que colabora do mesmo modo com uma associação para o narcotráfico (Lei 11.343/2006, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

2ª Vara

Av. Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502592-18.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502592-18.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR GOMES SANTOS CARVALHO e outro

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo Pinati da Silva

Vistos,

I - RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio de seu representante legal, em exercício nesta Comarca, no uso de suas atribuições legais, com base em incluso auto de inquérito policial, ofereceu denúncia contra VÍTOR GOMES CARVALHO e PABLO HENRIQUE CAVALCANTE OSWALDO, tendo-os por incurso no art. 33 e 55, ambos da lei 11343/06, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, imputando-lhes os seguintes fatos: [A] desde período incerto, mas que certamente perdurou 27 de julho de 2022, em local incerto, nesta cidade e Comarca de Cubatão, VITOR GOMES CARVALHO, qualificado às fls. 08/09, e PABLO HENRIQUE CAVALCANTE OSWALDO, qualificado às fls. 06/07, associaram-se com outros indivíduos não identificados para praticar, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes; [B] no dia 27 de julho de 2022, por volta das 6h30, na Rua Santa Terezinha, nº. 540, Área Rural, nesta cidade e comarca de Cubatão, VITOR GOMES CARVALHO, qualificado às fls. 08/09, e PABLO HENRIQUE CAVALCANTE OSWALDO, qualificado às fls. 06/07, traziam consigo, para fins de tráfico, 43 (quarenta e três) pedras de cocaína sob a forma de "crack", com peso líquido de 0,20g; 65 (sessenta e cinco) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 0,50g; 08 (oito) tiras de "maconha" (Tetrahydrocannabinol - THC), com peso líquido de 0,50g; 31 (trinta e uma) porções de "maconha" (Tetrahydrocannabinol - THC), com peso líquido de 0,30g; 17 (dezessete) porções de "skunk", com peso líquido de 0,15g, drogas causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,

conforme auto de exibição e apreensão de fls. 23/24, laudo de constatação provisória de fls. 17/18 e laudo de exame químico-toxicológico a ser oportunamente acostado aos autos.

Presos em flagrante, a prisão do corréu Vítor foi convertida em preventiva e ao corréu Pablo foi concedida a liberdade provisória [fls. 60].

Os réus foram notificados e citados [Pablo a fls.90 em 13/08/2022; Vítor a fls. 91 em 23/08/22] e, por intermédio de Defensor nomeado, apresentaram resposta à acusação [fls. 102/104].

Recebida a denúncia em 15 de setembro de 2022 [fls. 106/107], foi designada audiência, na qual foram colhidos os depoimentos de testemunhas, bem como realizado o interrogatório dos réus, com registro em mídia digital.

Em memoriais finais, o Ministério Público entendeu estar devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito, bem como a responsabilidade criminal dos réus, pugnando pela sua condenação, discorrendo sobre a dosimetria.

Por sua vez, em seus memoriais, a Defesa do réu pleiteou sua absolvição, sustentando não existir prova suficiente para a condenação [CPP, art. 386, VII] e, em caso de condenação, aplicação de pena mínima, regime diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Processo em ordem, com a presença das condições da ação e observância das formalidades legais, sem nulidades a sanar.

A reiterada preliminar de instauração de incidente de dependência químico-toxicológica fica afastada, conforme fundamentação nos autos [fls. 152/153 e 178/179].

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante [fls. 01], pelo boletim de ocorrência [fls.37/40], pelo auto de apreensão e exibição [fls.23/24], auto de constatação preliminar [fls. 17/18], laudo químico toxicológico [fls. 110/112], laudos periciais [fls. 291/295 e 299/308] e pela prova oral sob o crivo do contraditório.

A autoria é certa e deve ser imputada aos réus, porque comprovada pelo depoimento de testemunhas e confissão parcial.

Christian Beltrame de Souza, policial civil, informou, em fase policial [fls.04] que, durante operação policial, se dirigiu ao local, em companhia da Investigadora Christiane, para verificação da prática do tráfico de drogas em "biqueira" conhecida. Ingressaram a pé no local e depararam com dois homens, Vítor e Pablo. Vítor segurava uma sacola plástica de cor preta, sendo que durante a busca pessoal encontrou, em seu interior, maconha, cocaína, skank e crack, embaladas e prontas para a venda, além da quantia de R\$ 35,00 (trinta e cinco). Vítor disse que as drogas se destinavam ao comércio. Pablo nada trazia consigo, mas admitiu que trabalhava como olheiro da "biqueira" em troca de drogas, alegando ser usuário. O local é conhecido pelo tráfico de drogas.

Em igual sentido o depoimento de Christiane Martiniano de Souza, policial civil, quem informou, desde a fase policial [fls. 05], que, durante a operação policial, juntamente com o Investigador Cristhian, foi até o local até a Rua Santa Terezinha, para verificar a existência de "biqueira". Ingressaram a pé no local, próximo ao número 540, e notaram a presença de dois homens, Vítor e Pablo, em atitude suspeita. Vítor segurava uma sacola plástica de cor preta, sendo, então, realizada a busca pessoal em ambos. O policial Cristhian encontrou no interior da sacola porções de maconha, cocaína, Skank e crack, além da quantia de R\$ 35,00 (trinta e cinco reais) em dinheiro. Em poder de Pablo nada de ilícito foi encontrado. Pablo disse que exercia a função de olheiro do ponto de venda de drogas, alertando os vendedores sobre a chegada da polícia. Pablo não trazia consigo rádio comunicador. Alegou receber drogas para o sustento do seu vício. Vítor assumiu a propriedade da droga.

Interrogado em juízo, o corréu Vítor confessou os fatos. De fato, estava praticando o crime de tráfico de drogas por dificuldade financeira para consumo de drogas,

sendo "escravo da droga". Nega a associação para o tráfico. Conhecia o corrêu Pablo "de vista". Fazia um mês que estava traficando drogas. Não havia "olheiro" no período. Pablo estava indo à padaria para comprar pão. Pablo não estava ao seu lado quando da prisão e não confessou ser "olheiro". Estava sob efeito de drogas. Não foram presos no mesmo local.

Interrogado em juízo, o corrêu Pablo confessou em parte o crime. Estava realizando a prática de "olheiro", responsável por avisar a chegada de policiais no ponto de tráfico, na mesma "biqueira", por três vezes, a traficantes diversos, incluindo o corrêu Vítor, este apenas no dia da prisão. Negou a prática do tráfico de drogas. Essa é a prova oral constante dos autos.

Consigne-se que os inquiridos expuseram satisfatoriamente os fatos, sendo certo que os relatos são dignos de credibilidade, não se percebendo qualquer tentativa de falsear a verdade, porque convincentes e provenientes de pessoas cuja idoneidade não foi posta em dúvida, sem indícios de que possuíam interesse em prejudicar o acusado, a quem não conheciam, ignorando-se nos autos notícia de desavença ou fato pretérito que indicasse falsa incriminação.

Os réus confessaram, em parte, os fatos narrados na denúncia.

Vítor confessou o tráfico, negando a conduta imputada ao corrêu.

Pablo negou o tráfico, reconhecendo o exercício da atividade de olheiro, para outros traficantes além de Vítor.

A confissão foi essencialmente confirmada pelo seguro e harmônico depoimento dos policiais civis.

Destaca-se que, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais. Logo, fica claro que todos têm a obrigação de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha, excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e artigo 207, ambos do Código de Processo Penal. Aliás, os atos funcionais do servidor público são presumidos verdadeiros [CF, art. 37].

Assim, não se pode imputar conduta parcial genericamente aos policiais, que, no cumprimento da missão que lhes foi confiada pelo constituinte [CF, art. 144], apresentam transgressores da ordem jurídica ao Estado-Juiz para serem processados, segundo o devido processo legal, que fornece instrumentos para confirmar ou rechaçar a versão dos fatos apresentada pelos agentes estatais de segurança pública. Como assentado no E. Supremo Tribunal Federal, "[o] depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência" [STF - HC n. 73518, rel. Min. Celso de Mello, j. 26.3.1996]. Por oportuno, confira-se: "Urge destacar que nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, possam testemunhar sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública". [TJSP, Ap. n. 0000604-19.2016.8.26.0545, rel. Des. Herman Herschander, j. 07.12.2017]

A par disso, nenhuma das testemunhas foi contraditada na oportunidade própria e prestaram os depoimentos sob o dever de dizer a verdade.

No mais, toda prova tem valor relativo e deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz, inclusive a testemunhal [CPP, art. 155].

Desse modo, o fato alegado pelo réu, sem repercussão em elemento de prova objetivo ou subjetivo, não gera dúvida objetiva razoável em seu favor.

Induvidosa a apreensão, em poder do corrêu Vítor, dos entorpecentes descritos na denúncia.

Assim sendo, várias circunstâncias, devidamente demonstradas, conspiram para a formação de convicção da destinação mercantil da droga apreendida e da autoria do

crime: [a] a quantidade e modo de acondicionamento dos entorpecentes; [b] o local conhecido ponto de tráfico na Comarca; [c] a narrativa dos policiais civis; [d] a confissão parcial.

Inviável, pois, acolher-se a pretensão absolutória ou desclassificatória, ressaltando-se, ainda, que eventual condição de usuária não exclui a de traficante. Registre-se que para configuração do crime imputado aos réus não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, não se exigindo a tradição, para consumação do delito.

Assim, pois, é de se reconhecer que o corréu Vitor trazia consigo droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conduta que se amolda à figura típica prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11343/2006.

A desclassificação para informante colaborador é imperiosa, por isonomia.

Com efeito, a colaboração em comunicar grupo, organização ou associação destinada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes se configura pelo ajuste prévio [normalmente com o uso de rádio comunicador], com o intuito de garantir a impunidade dos traficantes que realizam a efetiva mercancia ilícita perante agentes do Estado que buscam combater a prática delitiva.

Leciona Guilherme de Souza Nucci que "(...) o intuito do legislador, ao adotar no tipo penal do artigo 37, da Lei nº 11.343/06, a teoria pluralista do concurso de agentes não foi a de alcançar aqueles que exercem funções habituais no tráfico, como o 'olheiro', pois este é coautor da conduta descrita no artigo 33, mas sim aqueles que normalmente não integram a associação criminosa, em suas diversas funções hierárquicas, mas acabam colaborando com informações privilegiadas e estratégicas para o exercício da traficância(...)". [Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Editora Forense, 8ª edição fl. 367]. Outrossim, "(...) o informante presta um auxílio aos associados no tráfico que às vezes é considerado secundário, mas na realidade não é. Avisar àqueles que atuam no tráfico que a polícia realizará uma operação e com isso impossibilitar a prisão em flagrante dos agentes do tráfico e também deixar a vida dos policiais mais vulnerável não é auxílio secundário. Não se pode confundir a participação simples como soltar "pipa" ou "papagaio" e fogos de artifício advertindo os associados no tráfico com uma ajuda que não é importante" [RANGEL, Paulo; BACILA, Carlos Roberto. Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 125].

A prova dos autos assegura que o réu estava em local conhecido pelos policiais como ponto estratégico utilizado para venda de drogas exercendo função de "olheiro", participação substancial para assegurar o êxito da efetiva empreitada criminosa levada a efeito por traficante corréu, quem trazia consigo e guardava entorpecentes, típica conduta de tráfico.

Inviável, em princípio, acolher-se a pretensão desclassificatória, porque correta a tipificação pelo tráfico, mediante a norma de extensão do art. 29 do Código Penal, não havendo que falar na falta ou insuficiência de provas ou desclassificação da conduta do réu para o delito do art. 37 da Lei nº 11.343/06, mormente porque a informação se dá a traficante solitário, e não a "grupo, organização ou associação".

E essa distinção legal viola a isonomia e proporcionalidade, conforme lição doutrinária bastante: "A tipificação da colaboração episódica como informante de um traficante isolado - pessoa que se dedica sozinha ao narcotráfico - gera intenso debate na doutrina e na jurisprudência. Existem três posições sobre o assunto: 1ª posição: O fato é atípico. Se a colaboração informativa for prestada em favor de um único traficante, e não para um grupo, organização ou associação, "a conduta do agente será atípica em face deste art. 37, diante da interpretação restritiva da lei penal."450 2ª posição: Não há o crime do art. 37 da Lei de Drogas, mas pode o agente que colabora como informante de apenas um traficante, de acordo com o caso, responder pela "participação no crime de tráfico (arts. 33, caput e § 1º, e 34)."451 Esse entendimento peca por consentir com a punição muito mais severa do agente que colabora eventualmente com informações prestadas a um traficante solitário (partícipe do tráfico), em relação àquele que colabora do mesmo modo com uma associação para o narcotráfico (Lei 11.343/2006, art. 37). 3ª posição: Defende a possibilidade de aplicação, por analogia in bonam partem, do art. 37 da Lei de

Drogas ao colaborador eventual que presta informações ao traficante solitário. É o nosso entendimento, também adotado por Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho: 'Não será atípica, pois em razão do disposto no art. 29 do CP, ele estará auxiliando o traficante e, como tal, deverá responder pelo delito por este praticado, como partícipe. Se, por exemplo, presta informações para um traficante solitário sobre o melhor local para a venda de drogas ou para a aquisição de drogas, responderá pelo crime de tráfico posteriormente executado. Porém, tal solução fere de morte o princípio da isonomia, pois neste caso receberá pena de cinco a 15 anos, enquanto se tivesse contribuído com um grupo de traficantes receberia pena de dois a seis anos. Não há razão para distinguir, principalmente porque a situação de quem contribui com apenas um traficante é menos grave do que aquela de quem contribui com um grupo de traficantes. A solução, justamente por isto, é a aplicação da analogia in bonam partem, de forma a ser alcançado pelo presente tipo penal também aquele que contribui com apenas um traficante, em razão da lacuna da Lei.'⁴⁵² [MASSON, Cleber. MARÇAL, Vinícius. Lei de Drogas - Aspectos Penais e Processuais. 2ª ed. Rio de Janeiro: Método, 2021, e-book].

A imputação fática permite qualificação jurídica distinta daquela indicada na denúncia, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. Trata-se da emendatio libelli que não cerceia a defesa, porquanto o réu se defende de fatos e não da capitulação jurídica.

Conforme acima fundamentado, a prova dos autos assegura a prática criminosa descrita no art. 37 da Lei n. 11.343/06.

Passa-se ao exame da adequação típica do crime de associação para o tráfico. Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas exige-se, além do concurso mínimo de duas pessoas, prévio ajuste entre agentes que comunguem o propósito de, reiteradamente ou não, praticarem as condutas previstas nos arts. 33, caput e §1º, e 34, da Lei n. 11343/2006, com certo grau de estabilidade e permanência, elemento subjetivo específico exigido para distinção de mera prática delitiva em concurso de agentes, sendo prescindível a efetiva realização das condutas criminosas referidas, por se tratar de crime formal e de perigo abstrato. A prova dos autos não assegura o preenchimento desses requisitos, porque a realidade retratada pela prova é inidônea para configurar um programa delinquencial estável e duradouro com meta comum de traficância, comprometendo a paz e a saúde públicas imputáveis aos réus.

Nada além da prisão no local há nos autos. O réu negou estabilidade e permanência, nada refutando sua alegação. Por si, a confissão da prática de olheiro juntamente com outros traficantes está isolada nos autos.

Assim, "Havendo dúvidas sobre o vínculo associativo dos réus, estável e permanente para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, impossível a condenação" [Ap. n. 0012135-83.2011.8.26.0220, rel. Des. J. Martins, j. 4.12.2014].

Assim sendo, o fato é típico e antijurídico, sendo certo que a significância da lesão ao bem jurídico tutelado impõe a incidência da norma penal, não estando o acusado amparado por qualquer causa de exclusão da ilicitude ou que afaste sua culpabilidade.

Passa-se à individualização da pena, nos termos do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, segundo o sistema trifásico, nos termos do art. 68 do Código Penal, atentando-se às circunstâncias legais, notadamente aquelas previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Corréu Pablo.

A culpabilidade, entendida como grau maior ou menor de reprovabilidade da conduta no caso concreto, é normal ao tipo. O acusado não registra maus antecedentes. A conduta social e personalidade ["deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio accidental na vida do réu" [Cezar Roberto Bitencourt, Tratado de Direito Penal, Parte Geral, v. 1, 12ª ed., Saraiva, 2008, p. 588], à míngua de elementos de provas objetivas desabonadores, são favoráveis ao réu. O motivo do crime integra sua definição

típica, e, portanto, a necessária censura consta na pena mínima abstrata. As consequências do crime são intrínsecas ao delito não exigindo maior reprimenda. Assim sendo, pena-base no mínimo legal.

Em segunda fase, fixada a pena-base no mínimo legal, não incide a atenuante da confissão espontânea, uma vez que, na esteira da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na Súmula n.º 231, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição de pena.

A pena definitiva é de 2 anos de reclusão com 300 dias-multa.

Em vista da situação econômico-financeira do réu, fixo o valor do dia multa em 1/30[um trinta avos] do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos [CP, art. 49], que será corrigido monetariamente na ocasião oportuna.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto, na forma do disposto no art. 33, caput, e seu § 2º, alínea a c/c § 3º, do Código Penal.

À vista da primariedade do agente, ressaltando, ainda, que, confirmando a tendência jurisprudencial, o Senado Federal (art. 52, X, CF) publicou em 15 de fevereiro de 2012 a Resolução nº 5/2012, suspendendo a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (HC nº 97.256/RS), cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito [CP, art. 44, § 2º, segunda parte], fixando-as em prestação de serviço à comunidade (art. 46, CP) em entidade a ser designada pelo juízo das execuções penais (LEP, art. 66, V, a) e prestação pecuniária (art. 45, §2º, CP) no importe de um salário mínimo nacional a ser revertido em favor de entidade designada pelo juízo da execução.

Por oportuno, registre-se: "No universo de perversidade e desesperança alimentado pelo tráfico, há casos singulares que a pena alternativa de prestação de serviços à comunidade em geral se revela mais eficiente na repressão e prevenção da criminalidade. São aqueles nos quais as circunstâncias do fato como a pequena quantidade de entorpecente e, principalmente, as condições pessoais do agente muitas vezes primário e de bons antecedentes, inclusive com trabalho lícito ou ainda na fase estudantil, não evidenciam a periculosidade que o cárcere procura conter como medida extremada de proteção social. Nem todo delito de tráfico traz, insita, a gravidade ou potencial ofensivo que justifique o encarceramento do seu autor. Essa é uma verdade nem sempre admitida. Impõe-se, assim, quando cabível e "socialmente recomendável" para não fugir à literalidade do artigo 44, § 3º, do CP, resposta punitiva alternativa à prisão, verdadeira sanção pedagógica, considerada, porque não, a baixa periculosidade, a prematuridade do indivíduo ou, mesmo, a revelada potencialidade de se reintegrar à coletividade. Busca-se, enfim, a regeneração individual, sem descurar-se da retribuição estatal, mas evitando-se o cárcere, lugar que deve ser reservado a hipóteses em que a periculosidade suplanta a esperança ou a mera expectativa de ressocialização, ainda lembre-se um dos fins da reprimenda penal" [Ap. n. 0000406-95.2015.8.26.0551, rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, j. 14.02.2017].

O local e a forma de cumprimento da pena serão definidas pelo Juízo da Execução. Fica o réu advertido de que no caso de descumprimento injustificado das restrições impostas, as penas restritivas de direitos serão convertidas em privativa de liberdade, conforme disposto no § 4º do artigo 44 do Código Penal, com seu recolhimento à prisão.

Considerando a substituição da pena privativa de liberdade, não se há falar em sursis, ressaltando-se a vedação prevista no do art. 44, caput, da Lei 11.343/06 [cf. REsp n. 1358147, rel. Min. Marilza Maynard, j. 18.4.2013].

Corréu Vitor

A natureza [crack], sem desprezar a diversidade, da substância entorpecente impõe maior reprimenda.

A culpabilidade, entendida como grau maior ou menor de reprovabilidade da conduta no caso concreto, é normal ao tipo. O acusado não registra maus antecedentes. A

conduta social e personalidade [“deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu” [Cezar Roberto Bitencourt, Tratado de Direito Penal, Parte Geral, v. 1, 12ª ed., Saraiva, 2008, p. 588], à míngua de elementos de provas objetivas desabonadores, são favoráveis ao réu. O motivo do crime integra sua definição típica, e, portanto, a necessária censura consta na pena mínima abstrata. As circunstâncias e consequências do crime são intrínsecas ao delito não exigindo maior reprimenda. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o impulso delitivo do agente, fato, todavia, que não agrava a pena por se tratar de circunstância neutra [cf. STJ - HC n. 217.819, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura].

Pena-base com acréscimo de um sexto.

Em segunda fase, concorrem a circunstância atenuante da confissão espontânea [CP, art. 65, III, d] com a circunstância agravante da reincidência [CP, art. 61, I; fls. 46, processo n. 1500207-73.2017.8.26.0536], razão pela qual, à luz da posição jurisprudencial dominante, ficam compensadas, sem alteração da pena, ausente condenação remanescente para juízo de reprovabilidade maior apto a afastar a compensação integral.

Pena intermediária sem alteração.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição de pena.

A reincidência afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Assim, pois, a pena definitiva é de 5 anos e 10 meses de reclusão com 583 dias-multa.

Em vista da situação econômico-financeira do réu, fixo o valor do dia multa em 1/30 [um trinta avos] do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos [CP, art. 49; Lei n. 11.343/06, art. 43], que será corrigido monetariamente na ocasião oportuna. O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, na forma do disposto no art. 33, caput, e seu § 2º, alínea b c/c § 3º, do Código Penal.

A detração penal [desconto do tempo de prisão provisória] para fins de abrandamento do regime prisional inicial [CPP, art. 387, §2º] é descabida na hipótese, por ausência do requisito objetivo.

Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos [CP, art. 44, I e III] e a suspensão condicional da pena [CP, art. 77, caput e II], especialmente à vista da vedação prevista no do art. 44, caput, da Lei 11.343/06 [cf. REsp n. 1358147, rel. Min. Marilza Maynard, j. 18.4.2013].

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e, em consequência:

[a] ABSOLVER VÍTOR GOMES CARVALHO e PABLO HENRIQUE CAVALCANTE OSWALDO da imputação do crime previsto no 35 da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

[b] CONDENAR VÍTOR GOMES CARVALHO, qualificado anteriormente, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com 583 dias-multa, no mínimo legal, por incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

[c] CONDENAR PABLO HENRIQUE CAVALCANTE OSWALDO, na forma do art. 383, do Código de Processo Penal, qualificado anteriormente, às penas de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, com 300 dias-multa, no mínimo legal, por incurso no art. 37 da Lei n. 11.343/06.

Dê-se à droga apreendida a destinação prevista no artigo 72, da Lei nº 11.343/06, preservada quantidade para eventual contraprova.

Atentando-se aos critérios de proporcionalidade previstos no art. 282 do Código de Processo Penal e dispensado o exame do fumus commissi delicti [existência do crime e indícios suficientes de autoria, na forma do art. 312, in fine, do Código de Processo Penal] pela fundamentação supra, afigura-se presente o periculum libertatis, porque, dada a dinâmica desenvolvida para o exercício da traficância, é de ser mantida prisão cautelar, mormente considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, para, ao final, ser condenado à prática de

crime equiparado a hediondo, cujo cumprimento se iniciará no regime fechado e estava traficando, de modo organizado droga altamente viciante [cocaína], cujos efeitos deletérios são por todos conhecidos, tudo a revelar que a liberdade do réu colocará em risco a ordem pública [CPP, art. 312], revelando-se insuficiente sua substituição por medida cautelar diversa [CPP, art. 282, §6º].

O corréu Pablo, desde o início, está solto.

Por fim, observo que, diante da prova no sentido de que o réu estava realizando a mercancia da droga, resta indiscutível que os bens apreendidos eram utilizados para a prática do tráfico ou dele derivada. Nessa situação, imperioso o perdimento. Inaplicável à hipótese a fixação do valor mínimo para reparação de danos [CPP, art. 387, IV] por se tratar de crime vago.

Após o trânsito em julgado: [a] expeça-se guia de execução e de recolhimento para encaminhamento ao juízo das execuções criminais; [b] notifique-se o condenado para pagamento da pena de multa, no prazo de dez dias, nos termos do art. 50, caput, do Código Penal [TJSP, Provimento CG n. 11/2015]; [c] oficie-se o TRE-SP, para os fins do art. 15, III, da CF; [d] oficie-se ao IIRGD para registro de antecedentes criminais.

Fixo os honorários advocatícios das patronas dos réus, nos termos do Convênio PGE/OAB, no máximo legal previsto na tabela, liberando-se 70% (setenta por cento) em caso de recurso e expedindo-se as competentes certidões.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas, nos termos do art. 804 do Código de Processo penal, ressaltando-se, como já se decidiu: "Ainda que os apelantes estejam assistidos pela Defensoria Pública, impõe-se a condenação ao pagamento das custas processuais, devendo a alegada miserabilidade jurídica ser examinada pelo Juízo da Execução, a fim e se conceder ou não a isenção reclamada (...)" [STJ, REsp 1416725/MG, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 29.06.2015].

P. I. C.

Cubatão, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA